

1501421-80.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... sacola do bolso. Nas proximidades, há ponto de tráfico. Já viu o acusado no meio do pessoal ligado ao tráfico.

A testemunha Camila Celestino afirmou conhecer o réu há dez anos, pois ele é filho de seu esposo. Na ocasião do fato, estava no bairro fazendo tranças em uma cliente. Trabalha como "trancista". Ele a acompanhava e foi comprar refrigerantes para as crianças. Soube ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501421-80.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501421-80.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2346177/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 22056758 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO,

10047/21/050 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2346177 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4,

10047/21/050 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 20 de dezembro de 2021, por volta das 13h55, na rua Luis Ferrari, quadra 01, Parque das Nações, nesta cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, 2,64 gramas de cocaína, 35,87 gramas de crack e 21,65 gramas de maconha, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 128), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 134/135.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 04 de abril de 2022 (fls. 143/145).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 186 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 214/218).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 222/235, alegando que: 1)- os policiais não viram o réu comercializando drogas; 2)- foi solicitada a juntada dos shorts usado pelo réu na data do fato, pois ele não poderia ter retirado a sacola de tal vestimenta, que não possuía bolso; 3)- a confissão informal não é elemento suficiente para a condenação; 4)- o réu faz bicos, de modo que não se pode afirmar ser o dinheiro produto do tráfico; 5)- os policiais não esclareceram as circunstâncias do flagrante. Pediu a absolvição e, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a fixação da pena no mínimo e do regime inicial aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 13/14 e pelo laudo pericial de fls. 110/114 (quinze porções de cocaína com peso de 2,64 gramas, cento e cinquenta e sete porções de crack com peso de 35,87 gramas e dezoito porções de maconha com peso de 21,65 gramas).

A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos ao acusado.

Em juízo, a testemunha Stephanie Franco Santos, policial militar, afirmou que estava em patrulhamento de rotina e visualizou o réu saindo da mata. Ele, a princípio, não notou a presença dos policiais. Quando estes se aproximaram, o acusado entrou num bar. Segundo seu parceiro, o suspeito dispensou uma sacola no chão. Verificou-se que havia droga na sacola. Não se recorda como o entorpecente estava acondicionado. Salvo engano, tratava-se de maconha. O réu retirou a sacola das vestes, para depois dispensá-la. Não viu em qual local a sacola ficou, depois de jogada no chão. Permaneceu na segurança, mas não sabe precisar a qual distância do acusado. Ouviu seu parceiro conversando com o réu, mas não se recorda do teor do diálogo. A mata se situava nas proximidades. Quando seu colega abordou o réu, ficou a aproximadamente um ou dois metros.

A testemunha Abner Pereira Amaral, também policial militar, relatou que, ao passar pelo local, viu um rapaz de costas, sem camisa e de shorts. Ele não viu, a princípio, a viatura. Quando o indivíduo percebeu a aproximação dos policiais, foi em direção a um bar, situado nas proximidades. Na porta do estabelecimento, que tem um desnível em relação à via pública, ele retirou uma sacola do bolso de seu shorts e a dispensou no chão.

Verificou o conteúdo da sacola e encontrou cocaína, maconha e crack. O indivíduo permaneceu na porta do bar. No início, ele negou a posse do material mas, depois, assumiu lhe pertencer. Havia uma moça trabalhando no bar. Na delegacia, a autoridade policial pediu que ela fosse conduzida. A viatura levou a atendente do bar na delegacia e, ali, ela disse que apenas trabalhava no estabelecimento e que nada viu. Não integrava a viatura que a foi buscar. O shorts era de tãtel e largo. O réu teve dificuldade para retirar a sacola do bolso. Nas proximidades, há ponto de tráfico. Já viu o acusado no meio do pessoal ligado ao tráfico.

A testemunha Camila Celestino afirmou conhecer o réu há dez anos, pois ele é filho de seu esposo. Na ocasião do fato, estava no bairro fazendo tranças em uma cliente. Trabalha como "trancista". Ele a acompanhava e foi comprar refrigerantes para as crianças. Soube posteriormente que o réu foi abordado e conduzido para a delegacia. Ele, inicialmente, estava com ela, e depois saiu para comprar refrigerantes para as crianças em um "barzinho". Não conseguia ver o bar do local onde estava, pois ficava duas quadras abaixo. O acusado vestia bermuda, salvo engano, de tãtel. Conseguiu avisar seu esposo somente depois, pois ele estava trabalhando. Compareceu na delegacia logo que soube da condução de seu enteado. Deixou sua filha na casa de seu avô e foi para a delegacia. Ali, prestou depoimento.

Interrogado em juízo, o réu declarou que estava com sua madrastra, algumas quadras para cima do bar. Desceu no bar para comprar guaraná. Os policiais o abordaram, apontaram arma para ele e para a menina que ali estava e determinaram que ela

saísse. Depois, eles reviraram o bar e o prenderam, levando-o. Não conhecia os policiais. Os que prestaram depoimento foram os que o abordaram. Não havia outros policiais. Somente viu a sacola na delegacia. Não conhece a menina que estava no bar. Já havia ido naquele estabelecimento quando outra mulher estava lá. Acompanhou sua madrastra porque ela não gostava de ir no Parque das Nações sozinha. O local da abordagem se situa a uma distância de sua casa que pode ser percorrida, de Uber, em trinta minutos. Naquele momento, Camila estava atendendo uma cliente, salvo engano de nome Evelin. Tinha uma nota de cinco reais e outra de dois reais. A moça lhe devolveu troco de um real. Chegou a comprar o refrigerante. Seu shorts não tinha bolso. A vestimenta foi encaminhada ao CDP.

Sobreveio nos autos a informação de fls. 200, prestada pelo Diretor do Centro de Detenção Provisória de Bauru: o shorts que o réu usava no momento da inclusão na unidade prisional em 02/02/2022 não está ali; no momento da inclusão, as vestimentas foram colocadas à disposição dos familiares e, caso não tenha havido a retirada, foram descartadas ou doadas.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

A prática do delito foi confirmada pelo depoimento insuspeito do policial militar Abner, o qual flagrou o réu dispensando uma sacola, em cujo interior estavam as porções de crack, cocaína e maconha apreendidas.

Não há motivo para não se atribuir credibilidade à palavra do policial.

No particular, é lícito questionar: por que razão um servidor público perderia seu tempo ao conduzir um terceiro até a delegacia de polícia e depois viria em juízo, a fim de afirmar fatos inverídicos em detrimento de pessoa que sequer ou pouco conhecia, correndo o risco de ser responsabilizado administrativa e criminalmente pela falsa acusação?

Ademais, as afirmações do policial se afiguram firmes, coerentes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de policiais.

À propósito:

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição.” (RT 610/369).

Em igual sentido:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

Não bastasse, a experiência tem demonstrado que, quando arroladas como testemunhas de tráfico pessoas de fora dos quadros da polícia, elas invariavelmente não dizem a verdade em juízo, pois não querem se expor a delatar publicamente um traficante, possivelmente com medo de eventuais represálias, ou mesmo por terem algum vínculo de intimidade ou amizade com a pessoa processada.

Saliente-se que a testemunha Camila não presenciou a abordagem nem o momento que imediatamente a precedeu, de modo que não teria como afirmar que o réu, de fato, nada trazia consigo de ilícito.

A alegação de que o shorts usado pelo acusado na data do fato não possuía bolso não restou provada.

Lembre-se que, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus de provar tal alegação competia à defesa.

Cabe ressaltar que a comprovação poderia ter ocorrido de forma simples, já que, conforme ofício de fls. 200, a vestimenta ficou à disposição, no Centro de Detenção

Provisória, por trinta dias.

Aquele era o momento para se requerer a exibição do objeto ou para que viessem aos autos as respectivas fotografias e mesmo perícia.

Aliás, nem havia razão para que a defesa supusesse que o shorts ainda estivesse em poder do Centro de Detenção Provisória de Bauru quando do requerimento formulado na audiência de 09/08/2022 (fls. 186), haja vista que o réu, beneficiado por liminar deferida em Habeas Corpus, houvera obtido liberdade provisória e deixado o estabelecimento prisional em 22/12/2021 (fls. 84/86 e 97/104), ou seja, apenas dois dias após a prisão em flagrante.

Na oportunidade da soltura, qualquer pertence do acusado que tivesse sido levado à unidade prisional já lhe teria sido restituído.

Assim é que o shorts em questão certamente foi devolvido ao proprietário, de modo que ele próprio poderia tê-lo exibido ou o apresentado às autoridades.

A inércia, no ponto em questão, é sintomática.

A tudo some-se que, segundo verte da prova oral, tratava-se de uma vestimenta de tãtcl, material bastante maleável e que permite expansão, a depender do material que está a envolver.

Não causa espécie, destarte, que, no bolso do shorts, tenham cabido porções de drogas que, no total, pesavam meros 60,16 gramas (2,64 gramas de cocaína, 35,87 gramas de crack e 21,65 gramas de maconha).

Por outro lado, não há dúvida de que o réu estava cometendo tráfico.

Afinal, um simples usuário não iria transitar em via pública com 15 porções de cocaína, 157 porções de crack e 18 porções de maconha.

O próprio acusado não desconhecia tal evidência, tanto assim que nem se atreveu a sustentar que pretendia consumir o material transportado, preferindo, ao revés, negar a respectiva propriedade.

De resto, cabe observar que o art. 33, caput, da Lei Antidrogas define crime de conteúdo múltiplo e de perigo abstrato.

Dessa forma, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos ali descritos, desde que sem a finalidade de consumo da droga, para que o delito de tráfico reste caracterizado.

Não é indispensável, assim, que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia de droga, sendo suficiente que a traga consigo (conforme descrito na denúncia e comprovado na instrução).

Destarte, não há como absolver, e nem mesmo como desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.

Em suma, deve o réu ser condenado por tráfico.

Passa-se à aplicação da pena.

O réu é primário e não registra antecedentes (fls. 38).

Diante disso, fixa-se a pena base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa.

Deve ser aplicado o privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

Destaque-se que a quantidade de droga apreendida não era das mais elevadas, não sendo possível inferir, a partir daí, que o réu se dedicava a atividade criminosa. Ademais, nenhum outro elemento de convicção autoriza concluir que se está diante de agente que integra organização criminosa ou que se dedica ao tráfico de forma contumaz.

Cabível o privilégio, afigura-se justo deferir a diminuição no grau máximo de dois terços, tendo em vista que as quantidades de drogas e de dinheiro apreendidas não foram das mais elevadas.

Destarte, a pena resulta em um ano e oito meses de reclusão, mais cento e sessenta e seis dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena para o tráfico, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes

hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015). Ainda, no julgamento do Habeas Corpus nº 137458/SP, o Ministro Gilmar Mendes assim dissertou:

"Destaco que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto, atentando-se aos preceitos estabelecidos no art. 33, § 2º, do Código Penal. Assim, não sendo a paciente reincidente, nem tendo contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), a hediondez do crime não constitui motivação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso. Fixo, ainda, o regime aberto de início do cumprimento da pena".

Assim, ausente a obrigatoriedade de fixação do regime inicial fechado para o tráfico, cabe analisar as circunstâncias do caso concreto, a fim de se definir o regime no qual o acusado começará a cumprir a sanção.

Considerando as circunstâncias expostas (primariedade, ausência de antecedentes, quantidades não elevadas de droga e dinheiro), fixa-se o regime inicial aberto. Levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme apontado, entende-se cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

E ainda:

"Entorpecente Absolvição ou Desclassificação - Impossibilidade - Provas seguras que demonstram a prática do delito de tráfico. Penas fixadas no mínimo e aplicado redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 no percentual de 1/5 - Redução em 2/3 Possibilidade. Penas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Cabimento. Regime prisional inicial fechado Fixação conforme preceitua o § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 Apelação do réu provida parcialmente." (TJSP, Apelação n. 0006628-72.2010.8.26.0319, rel. Pedro Menin, j. 10/04/2012).

Assim, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo das penas aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o acusado Gabriel Henrique dos Santos como incurso nas penas do artigo 33, caput e §4º, da Lei 11.343/06, a cumprir um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, calculado o valor do dia multa no piso mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena

aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução. Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

Declaro a perda em favor da União, e a reversão ao Funad, do numerário em dinheiro apreendido nos autos, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal, e art. 63, § 1º, da Lei n. 11.343/2006.

Ante a pena imposta, expeça-se alvará de soltura.

P.R.I.

Bauru, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA